

1500285-33.2019.8.26.0557

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO HENRIQUE ANTUNES MOTTA GOMES

Comarca: Viradouro

Foro: Foro de Viradouro

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 20/05/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WALDEMIR ANTONIO MATRICARDI e outros

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO HENRIQUE ANTUNES MOTTA GOMES

Vistos e examinados os presentes autos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu(sua) representante que oficia perante este Juízo, aforou a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Viradouro

Foro de Viradouro

Vara Única

Rua José Borelli, 10, Viradouro - SP - cep 14740-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença nos autos sob o n. 1500285-33.2019.8.26.0557 - lauda de SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500285-33.2019.8.26.0557

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WALDEMIR ANTONIO MATRICARDI e outros

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO HENRIQUE ANTUNES MOTTA GOMES

Vistos e examinados os presentes autos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu(sua) presentante que oficia perante este Juízo, aforou a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA, na qual denuncia WALDEMIR ANTÔNIO MATRICARDI, MARCIANO PIRES SIMÕES e CARLOS ROCHA ARAÚJO, como incurso(s) na prática do(s) delito(s) tipificado(s) no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 29 do Código Penal, ao argumento de que, no dia 17 de abril de 2019, por volta das 20h10, na Rua Jaime Amâncio, 20, Centro, na cidade de Terra Roxa, nesta Comarca, eles, previamente ajustados e com unidade de desígnios, transportavam e traziam consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico, 26 (vinte e seis) microtubos plásticos do tipo eppendorf acondicionando a substância conhecida como "cocaína", com peso líquido de 7,95g (sete gramas e noventa e cinco miligramas), 05 (cinco) porções da droga conhecida como "maconha", com peso líquido de 7,85g (sete gramas e oitenta e cinco miligramas), e 02 (dois) invólucros plásticos acondicionando a substância conhecida como "crack".

Os acusados foram presos em flagrante (f. 01/10) e as prisões foram relaxadas em sede de audiência de custódia (f. 64/66).

Os acusados foram notificados (f. 167, 237 e 257) e apresentaram defesa preliminar (f. 177/189, 228/230 e 290/297).

A denúncia foi recebida no dia 16 de julho de 2021 pela decisão de fls. 306/309 e os réus foram citados.

Na audiência de instrução e julgamento, foram inquiridas as testemunhas e, por fim, interrogados os réus.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público pediu a procedência da denúncia em relação aos acusados MARCIANO e CARLOS, com absolvição de WALDEMIR.

A Defesa de WALDEMIR, por sua vez, pediu a absolvição do acusado, destacando a fragilidade de provas e reiterando o pedido da Acusação.

A Defesa de MARCIANO pediu a desclassificação para o crime de porte de droga para consumo próprio, apontando a fragilidade de provas para denotar a traficância.

A Defesa de CARLOS argumentou no mesmo sentido, acrescentando a tese da participação de menor importância.

Enfim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

O feito encontra-se em ordem. Não há preliminares a dirimir. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, pertinente a análise do mérito da causa.

Cuida-se de ação penal pública, na qual a acusação imputa a prática de fato tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 29 do Código Penal.

Passo a análise da prova oral produzida.

A testemunha LUIS HENRIQUE DA SILVA, policial militar, ouvido na fase de inquérito (f. 02), declarou: "Na data de hoje, via telefone da base, recebemos uma denúncia anônima, dando conta que três indivíduos, entre eles, o senhor Matricardi, o qual faria um tipo de frete para traficantes da região, iriam buscar droga na cidade de Bebedouro/SP, para fins de traficância, o senhor Matricardi iria receber pelo frete da droga, levando e trazendo os outros dois com a droga que iria para um traficante do bairro Nossa Senhora Aparecida, de vulgo 'Moschem', ainda, o denunciante disse que o Matricardi faria uso do seu carro, um FIAT UNO, de cor prata, placas GRP 3797, especificamente, com detalhes, o denunciante nos disse que o veículo viria pela Rodovia que liga Terra Roxa a Bebedouro e entrariam pela Av. Novo Tempo, então

ficamos patrulhando nas imediações, com vistas ao referido veículo, em dado momento, avistamos o FIAT UNO, acima descrito, entrando na cidade de Terra Roxa/SP, onde, de pronto, tentamos efetuar a abordagem, com sinais sonoros e luminosos, porém o senhor Matricardi, que estava no volante do FIAT UNO tentou empreender fuga, porém sem êxito, pois foi fechado pela viatura policial. No interior do veículo encontravam-se o indiciado Matricardi, Carlos Rocha e Marciano. No volante estava Matricardi, no banco dianteiro do passageiro, o indiciado Marciano e no banco traseiro o Carlos Rocha. Nós os abordamos, ordenando que descessem do veículo, com as mãos sobre a cabeça, e o soldado Bertolotti procedeu a busca pessoal em cada um dos indiciados, com o indiciado Carlos Rocha Araújo, em suas vestes, foram localizados vinte e seis pinos de cocaína e cento e doze reais em dinheiro, com o indiciado Marciano, em suas vestes, Bertolotti encontrou cinco trouxas de maconha e duas pedras de crack, com o indiciado Matricardi, em suas vestes, o Bertolotti localizou a quantia de duzentos e quinze reais em dinheiro. Com cada um dos indiciados foi encontrado um aparelho celular, ainda, em busca no interior do veículo de Matricardi, encontrei três facas, uma banco da frente do motorista e duas no porta malas do automóvel. Indagados, Matricardi alegou que não sabia que os indivíduos estavam transportando droga e que havia apenas levado eles para receber um dinheiro na Caixa Econômica Federal de Bebedouro. Carlos Rocha, indagado, disse que Matricardi faz esse tipo de frete e que seria usuário de cocaína e a droga seria para seu consumo. Indagado, Marciano disse que a maconha e o crack não eram dele e que havia ido em Bebedouro para receber um dinheiro. Diante dos fatos, os indiciados receberam voz de prisão e conduzidos ao Plantão de Viradouro/SP".

Em juízo, disse que houve ligação anônima no telefone da base; a informação dava conta que MATRICARDI fazia serviços para traficantes e teria ido para Bebedouro com mais dois indivíduos; relatou-se o veículo, a cor e a placa; na saída da cidade, o veículo foi visualizado; o condutor não obedeceu o sinal de parada e tentou fugir, contudo, não conseguiu; com CARLOS, havia eppendorfs; com MARCIANO, havia maconha e crack; MATRICARDI tinha dinheiro consigo; MATRICARDI disse que levou os indivíduos para sacar um dinheiro na Caixa Econômica Federal; os demais disseram que eram usuários de drogas; as drogas estavam em bolsos; não sabe o relacionamento entre os três indivíduos; ele fazia serviços tipo "Uber"; depois do flagrante, nunca mais apareceram denúncias envolvendo MATRICARDI; de vez em quando, o vê; não o viu mais em atividade suspeita.

A testemunha LUIZ EDUARDO BERTOLOTTI, policial militar, ouvido na fase investigativa (f. 04), relatou: "Na data de hoje, de serviço com o policial militar Luís Henrique, via telefone móvel da base, recebemos uma denúncia anônima, o denunciante informando que três indivíduos, um deles de Matricardi, o qual faria um frete para traficantes da região, os quais iriam buscar droga na cidade vizinha de Bebedouro/SP, para fins de comercialização na cidade de Terra Roxa, o iria receber Matricardi iria receber pelo frete da droga, levando e trazendo os outros dois com a droga que seria comercializada no bairro Nossa Senhora Aparecida, para um traficante de vulgo 'Moschem', ainda, o denunciante disse que o Matricardi faria uso do seu carro, um FIAT UNO, de cor prata, placas GRP 3797, com detalhes, o denunciante nos disse que o veículo viria pela Rodovia que liga Terra Roxa a Bebedouro e entrariam pela Av. Novo Tempo, eu e Luís Henrique ficamos patrulhando nas imediações, com vistas ao referido veículo, em determinado momento, avistamos o FIAT UNO, acima descrito, entrando na cidade de Terra Roxa/SP, onde, de imediato, tentamos efetuar a abordagem, com sinais sonoros e luminosos, porém o senhor Matricardi, que estava no volante do FIAT UNO tentou se evadir, porém sem êxito, pois foi fechado pela viatura policial e teve a marcha do veículo interrompida. No interior do veículo encontravam-se os indiciados Matricardi, Carlos Rocha e Marciano. No volante estava o indiciado Matricardi, no banco dianteiro do passageiro, o indiciado Marciano e no banco traseiro o indiciado Carlos Rocha. Nós os abordamos, ordenando que descessem do veículo, com as mãos sobre a cabeça, e o soldado Henrique me deu cobertura, então procedi a busca pessoal em cada um dos indiciados, com o indiciado Carlos Rocha Araújo, em suas vestes, localizei em uma sacolinha de cor branca, vinte e seis pinos de cocaína e cento e doze reais em

dinheiro, com o indiciado Marciano, em suas vestes, encontrei cinco trouxas de maconha e duas pedras de crack, com o indiciado Matricardi, em suas vestes, localizei a quantia de duzentos e quinze reais em dinheiro. Com cada um dos indiciados foi encontrado um aparelho celular, em busca no interior do veículo de Matricardi, Luís Henrique encontrou três facas, uma banco da frente do motorista e duas no porta malas do automóvel. Indagados, Matricardi disse que não sabia que os indivíduos estavam transportando droga e que havia apenas levado eles para receber um dinheiro na Caixa Econômica Federal de Bebedouro. Carlos Rocha, indagado, disse que Matricardi faz esse tipo de frete e que seria usuário de cocaína e a droga encontrada consigo seria para seu consumo. Indagado, Marciano disse que a maconha e o crack não eram dele e que havia ido em Bebedouro para receber um dinheiro. Diante dos fatos, os indiciados receberam voz de prisão e conduzidos ao Plantão de Viradouro/SP".

Em juízo, disse que a ocorrência se originou por denúncia que relatava que "MATRICARDI" estaria trazendo droga para a cidade de Bebedouro e deu todos os detalhes; passou a placa do carro, um veículo UNO; começaram a fazer patrulhamento; viram o acusado entrar na cidade; tentaram abordá-lo com sinais sonoros e luminosos; o condutor esboçou uma fuga e tentou dar ré quando o veículo foi fechado; MATRICARDI estava no volante e tinha dois passageiros, CARLOS e MARCIANO; MARCIANO estava no banco da frente e foi encontrada maconha e crack; com CARLOS, havia pinos e dinheiro; com MATRICARDI, havia dinheiro; MATRICARDI seria uma espécie de "Uber do tráfico"; foram encontrados três celulares; foram apresentados na Delegacia de Polícia; MATRICARDI disse que sacou o dinheiro; CARLOS disse que era usuário; MARCIANO disse que a droga não era dele; a droga que estava com CARLOS que estava em um saco plástico encontrado com ele, ele tinha a posse do saco; não havia nada solto no veículo, estava na posse dos indivíduos; sabe que MATRICARDI não tem relação com os dois acusados, mas não sabe desses dois entre si; eles disseram que haviam pegado uma carona com MATRICARDI; não conhece essas pessoas dos meios policiais; começou a ver mais MATRICARDI posteriormente; o depoente nunca flagrou MATRICARDI em outra atitude suspeita; logo depois, MATRICARDI sofreu um acidente com animal na pista e perdeu o veículo; a denúncia foi feita via base da Polícia Militar de Terra Roxa; acredita que há extrato da denúncia que possa ser solicitado;

O acusado WALDEMIR ANTONIO MATRICARDI, ouvido perante a autoridade policial (f. 06), respondeu: "O mais baixinho é meu vizinho, o Marciano, o outro eu não conheço. O Marciano me procurou hoje, dizendo que a lotérica já havia fechado e ele precisava ir até a agência da Caixa Econômica Federal de Bebedouro/SP, para sacar um dinheiro, em troca ele me daria trinta reais para levá-lo até lá, aceitei a proposta do rapaz, o Marciano, saímos lá do bairro Nossa Senhora Aparecida, eu e o Marciano, no caminho, ainda em Terra Roxa/SP, o Marciano me pediu para pegar um amigo dele, na rodoviária de Terra Roxa, pois esse indivíduo iria ajudar o Marciano a mexer no caixa eletrônico. Peguei o rapaz na rodoviária de Terra Roxa/SP e fomos embora para Bebedouro, os dois desceram e foram até o caixa eletrônico da Caixa Econômica Federal, na Praça de Bebedouro, enquanto isso eu fiquei no carro, esperando os dois. Depois de uns cinco minutos, os dois voltaram do caixa eletrônico para o meu carro e voltamos para a cidade de Terra Roxa/SP. Quando chegamos em Terra Roxa, na entrada, os policiais nos abordaram, revistaram-nos, e eu não sabia que os dois rapazes que estavam comigo tinham droga. Vi quando os policiais militares encontraram a droga com os dois rapazes. Só soube que os dois estavam com droga por causa dos policiais que encontraram o negócio com eles. Não tenho nada a ver com o tráfico de droga, sou inocente, se soubesse que eles estavam com droga, não os teria levado até Bebedouro/SP. Os policiais encontraram um valor comigo, acho que cento e oitenta reais, dinheiro meu, de aposentado, que recebi faz poucos dias atrás".

Em juízo, disse que o depoente faz "corridas" na região há mais de 15 anos; os dois outros acusados pediram para leva-los em Bebedouro, na Caixa Econômica Federal para pegar um dinheiro; foram lá; eles demoraram alguns minutos e vieram embora; pararam para comprar uma latinha de cerveja; o depoente não sabia o que estava acontecendo; os demais acusados forçaram o depoente a correr com o carro, mas depois parou; não

tinha conhecimento que eles transportavam droga, senão tinha largado eles no local; conhecia MARCIANO anteriormente, que foi seu vizinho; não conhecia o outro acusado; buscou CARLOS na rodoviária a pedido de MARCIANO; foi contratado para ir e voltar de Bebedouro; o depoente cobrou, salvo engano, R\$ 60; o depoente tinha consigo o dinheiro da sua aposentadoria e o dinheiro de algumas corridas; nunca percebeu que MARCIANO "mexia" com drogas; esclarece que, chegando em Bebedouro, deixou-os na porta da agência do banco e esperou em local próximo; demorou 10 a 15 minutos; ainda passaram em um bar e cada um comprou uma lata de cerveja; foram os dois que sugeriram passar no bar e inclusive pagaram a cerveja para o depoente; sempre tem pessoas fumando drogas na sua rua; o depoente nunca foi pago para buscar droga; aliás, não pergunta o que a pessoa vai fazer ou o que ela traz consigo; um motoqueiro entrou na agência ao mesmo tempo em que os acusados estavam na agência; não viu nada de extraordinário no bar, apenas um desceu do carro e levou dois minutos.

O acusado MARCIANO PIRES SIMÕES, ouvido em solo policial (f. 05), relatou: "Sou de fora do Estado de S. Paulo, não tenho para quem comunicar minha prisão. Não tenho advogado constituído para este ato. Saí às 04:50 horas da manhã para ir trabalhar na roça e retornei para casa às 17:20 horas, então resolvi ir até a lotérica de Terra Roxa para retirar um dinheiro, mas eu estava sem o RG, então nesse momento passou o tiozinho do UNO e eu pedi para ele me dar uma carona até a cidade de Bebedouro, para retirar o dinheiro no caixa lá. O homem do UNO pegou um outro rapaz na rodoviária em Terra Roxa, acho que seu nome é Carlão. Não sei o que o Carlão ia fazer em Bebedouro, eu ia tirar dinheiro no caixa. O tiozinho me cobrou trinta reais para me levar até a cidade de Bebedouro, não sei se ele cobrou algo do Carlão, mas fomos os três juntos. Eu desci do carro e fui até o caixa eletrônico, o Carlão ficou no carro com o tiozinho. Saquei a quantia de setenta e cinco reais e voltei para o carro. Voltando para a cidade de Terra Roxa, ainda em Bebedouro, no Mutirão, encontramos um cara, eu perguntei para esse cara se ele tinha droga para vender, o cara tinha uma droga, maconha, e comprei dele, pagando a quantia de cinquenta reais, cinco tolinhas, que eu iria usar. O tiozinho ficou no bar, enquanto eu fui comprar a droga, o Carlão também estava no carro, não sei bem. Depois a gente veio embora e a Polícia nos parou em Terra Roxa. Comigo havia apenas cinco tolinhas de maconha, não tinha crack comigo não e nem cocaína. Eu não sabia que o Carlão estava com cocaína, só soube quando os policiais revistaram ele. Não havia dinheiro comigo. Gastei todo o dinheiro que eu saquei no caixa eletrônico. Fui eu que paguei os trinta reais para o tiozinho do UNO".

Em juízo, nega os fatos; o depoente mora em Minas Novas e foi trabalhar em Terra Roxa no plantio de cana; pegou um dinheiro na caixa; passou em um lugar e comprou porção de maconha e duas pedras de crack; conhecia WALDEMIR, que morava próximo ao depoente; CARLOS trabalha com o depoente; CARLOS não vende drogas; acha que CARLOS é usuário de cocaína; comprou a droga em um local chamado "Mutirão"; não sabe o endereço; era um lugar alto em que passaram; comprou a droga ao parar no bar; comprou a droga por R\$ 70, valor pago pela maconha e crack em conjunto; foi para Bebedouro sacar um dinheiro na Caixa Econômica Federal; era dinheiro do seu trabalho; WALDEMIR não sabia que tinham comprado a droga; pagaram WALDEMIR pelo transporte.

O acusado CARLOS ROCHA ARAUJO, inquirido na Delegacia de Polícia (f. 07), respondeu: "Não tenho para quem comunicar minha prisão, sou de outro Estado e estou na região só para trabalhar. Não tenho advogado constituído para este ato. O meu colega Marciano me disse que teria de tirar um dinheiro em Bebedouro, pois já havia passado das seis horas. O Marciano me chamou para ir com ele sacar o dinheiro em Bebedouro e eu aceitei ir. O tiozinho do UNO já veio com o Marciano e o dinheiro da viagem a gente rachou no meio, eu paguei a metade e o Marciano a outra metade. Fomos para Bebedouro, o meu amigo sacou o dinheiro e ficamos rodando por lá, tomamos uma cerveja em um bar, o tiozinho do UNO bebeu um guaraná, aí passaram uns caras por lá e eu logo pensei que eles teriam o que eu queria, ou seja, cocaína, eles disseram que iriam arrumar cocaína, pediram para a gente aguardar, depois de dez minutos eles vieram e me deram vinte e seis pinos, que eu paguei a quantia de duzentos e sessenta reais e iria cheirar tudo. O meu colega Marciano comprou droga,

mas em outro lugar. Nas duas vezes, o tiozinho ficou meu longe, enquanto a gente comprava a droga. Na volta a Polícia pegou a gente, os pinos que estavam comigo eram para o meu uso”.

Em juízo, disse que contratou o serviço de “táxi” para ir na Caixa Econômica Federal; na volta, achou a oportunidade de comprar drogas; não tinha conhecimento de quem vendia drogas em Terra Roxa, então aproveitou para comprar cocaína; MARCIANO era seu colega de trabalho; não conhecia WALDEMIR; MARCIANO contratou WALDEMIR; não sabe se MARCIANO vende ou usa drogas; pagou cerca de R\$ 250 na droga; o depoente foi até a Caixa, porque em Terra Roxa a lotérica estava fechado; trabalharam no plantio de cana durante a manhã e foram a tarde; sacou mais de R\$ 300; o depoente não tem renda fixa; o depoente ganhava cerca de R\$ 1000, mas dependia da produção; não se recorda o valor do pino; era usuário de drogas há alguns meses; não continua usando, porque é muito difícil conseguir a droga. Pois bem.

Em relação ao acusado WALDEMIR, o presentante do Ministério Público pede a absolvição do acusado em relação ao delito imputado na exordial. A Constituição Federal adotou o sistema acusatório – de caráter essencialmente democrático –, que impõe a separação das funções concernentes à persecução penal, a saber, a de julgamento (pelo juiz), de acusação (pelo Ministério Público) e a de defesa. Diante disso, o art. 385 do Código de Processo Penal é de duvidosa recepção pela ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988. É questionável se o juiz natural pode substituir-se ao acusador constitucional (Ministério Público ou querelante) e condenar na falta de pedido condenatório por parte do órgão competente, já que a ausência de pedido de condenação equivale à ausência mesma de acusação. Não fosse por isso, entendo que as provas dos autos não sustentam uma conclusão condenatória. E isto porque vê-se que referido acusado não foi encontrado com drogas e não há nenhuma prova da sua adesão subjetiva à conduta dos acusados, aliás, não há prova sequer que ele teria conhecimento das drogas que foram encontradas com os passageiros,

Quanto aos demais acusados, não há dúvidas que eles possuíam drogas, o que eles mesmos confessam. O acusado CARLOS trazia consigo 26 microtubos plásticos tipo eppendorf contendo cocaína com peso líquido de 7,95 gramas. O acusado MARCIANO tinha consigo cinco porções de maconha com peso líquido de 7,85 gramas e dois invólucros plásticos contendo crack.

Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o delito do art. 28 da Lei n. 11343/06 é tipo incongruente, ou seja, o tipo subjetivo está além do tipo objetivo, o que equivale a dizer que se exige o elemento subjetivo específico de consumir a droga que porta. Em outros termos, para a condenação no delito do art. 33 da Lei n. 11343/06, e não no art. 28, exige-se que se afaste, com segurança, a finalidade do consumo próprio (REsp n. 1134610/MG, rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, j. 19.08.2010). Apenas quando afastada essa possibilidade, com segurança, será possível a condenação no tipo do tráfico de drogas, esse sim congruente simétrico, em que o tipo objetivo coincide com o tipo subjetivo, o que significa dizer que não se exige elemento subjetivo.

Na espécie, verifico que remanesce dúvida razoável acerca da destinação que os acusados pretendiam dar a droga, não sendo possível afastar com certeza a finalidade de consumo próprio.

Em que pese ser valoroso o depoimento dos policiais militares, esta não tem valor absoluto. Sem pretender qualquer crítica, sabe-se que a atuação policial é uma atividade administrativa que se situa em um contexto de tensão de direitos fundamentais, de modo que seria ingenuidade recorrer acriticamente ao dogma da presunção de regularidade dos atos dos agentes dos poderes públicos, confundindo vigência (existência do ato e regularidade formal) com validade (conteúdo material constitucionalmente conformado). Neste sentido, LUIGI FERRAJOLI destaca que “diversamente dos outros ramos da administração pública, é uma atividade em contato direto com as liberdades fundamentais” (Diritto e Ragione. 1998, p. 798, em tradução livre). Assim, para a doutrina especializada, a condenação baseada exclusivamente na palavra dos policiais militares deve reunir dois requisitos: a impossibilidade de produção de qualquer outra prova e a coerência entre os relatos

policiais (CARVALHO, Salo de; WEIGERT, Mariana de Assis Brasil e. Depoimentos Policiais e Regras de Experiência no Juízo de Tipicidade dos Crimes dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06: O caso Rafael Braga. Parecer, 2017, p. 19-20).

Em relação à denúncia anônima, consta que os policiais militares condutores teriam recebido a informação, via ligação para a base da polícia militar, informando que a pessoa de sobrenome MATRICARDI vinha de Bebedouro trazendo drogas com a finalidade de traficância, descrevendo o veículo e sua placa.

Entretanto, não veio aos autos extrato de denúncia anônima, transcrição ou qualquer outro documento em que conste o registro das informações recebidas pela Polícia Militar a fim de permitir o confronto entre o que foi denunciado e o que foi efetivamente encontrado no local pelos agentes de segurança.

Sem saber o conteúdo da denúncia, também não se sabe ao certo o que o(a) denunciante viu e se estaria ele(a) apto a distinguir o uso da distribuição da droga, o que pode não ser tão simples aos olhos do leigo. Conferir total credibilidade a esta informação significaria, na realidade, transferir a este anônimo denunciante a posição de julgador deste processo, pois estaria ele verdadeiramente realizando a classificação jurídica do fato imputado.

Isto não significa desprezar a importância de denúncias anônimas ou ignorar o fato de que muitas vezes são feitas de forma anônima justamente pelo temor que o(a) denunciante tem de ser identificado perante os potenciais criminosos denunciados. No entanto, além da privação do acusado de exercer o direito ao confronto, não se pode desconsiderar que o anonimato isenta o denunciante de qualquer responsabilidade caso empenhe declaração falsa, diferentemente de testemunha identificada, sujeita às penas do crime de falso testemunho. Infelizmente, a prática revela que denúncias anônimas podem ser, por variados motivos, desde trotes de adolescentes até pessoas mal-intencionadas com o único objetivo de causar constrangimento a inocentes com quem tenham alguma inimizade. Estatísticas oficiais mostram que entre 15 a 20% das ligações recebidas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo via 190 são trotes, o que equivale a aproximadamente 5.000 chamadas por dia (informação retirada de notícia jornalística disponível em <https://jovempan.com.br/programas/jornal-da-manha/pm-sp-trote.html>).

Em regra, denúncias anônimas não são suficientes para imediatamente justificar medidas invasivas, mas tão somente para dar início a diligências preliminares de averiguação, tais como campanas, por exemplo. O Superior Tribunal de Justiça reiteradamente decide que “denúncia anônima não é fonte probatória, mas mera informação, passível de gerar movimentação investigatória preliminar, mas jamais fundamento para a restrição a direitos individuais” (RHC n. 53134/RJ. Sexta Turma. Rel. Min. Nefi Cordeiro. DJe: 26/05/2015).

No mais, o depoimento dos policiais militares, embora valoroso, no ponto em que reproduzem a denúncia anônima, constituiu tão somente o que a doutrina convencionou chamar de hearsay witness, ou seja, eles são testemunhas indiretas, já que apenas puderam reproduzir informações que obtiveram por meio de contato com terceiros.

Afinal, a testemunha deve depor pelo que sabe por sentido próprio, não pelo sentido de outrem. Na linha da jurisprudência norte-americana, o testemunho de ouvir-dizer somente terá valor mais elevado nas hipóteses em que se comprove que a(s) pessoa(s) fonte da informação não estão disponíveis por razão de força maior ou que possa ser imputada à pessoa acusada.

Neste contexto, seria imprescindível, para o valor probatório da informação colhida, que a pessoa fonte desta informação, reproduzida pela testemunha policial, tivesse sido ouvida em Juízo, sob pena de privar a Defesa do direito ao confronto da testemunha, desdobramento do direito ao contraditório. No direito comparado, diz a VI Emenda à Constituição dos Estados Unidos da América: “in all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right (...) to be confronted with the witness against him” (em livre tradução, em todas as perseguições criminais, o acusado terá direito de ser confrontado com a testemunha que deponham contra ele).

Ensina a doutrina:

A ideia central é que o right of confrontation impõe que todo o saber testemunhal incriminador passível de valoração pelo juiz seja produzido de forma pública, oral, na presença do julgador e do acusado e submetido à inquirição deste último. Logo, a

declaração de uma determinada testemunha não pode ser admitida como elemento de prova contra o acusado, a não ser que ela tenha sido prestada nas sobreditas condições. (BADARÓ, Gustavo. A utilização da hearsay witness na Corte Penal Internacional: Estudo sobre sua admissibilidade e valoração. Zeitschrift Für Internationale Strafrechtsdogmatik, Gießen, n. 4, p.177-188, 2014).

Em outra lição:

O direito ao confronto possui um conteúdo normativo multifacetado, se consubstanciando no direito fundamental do acusado: (i) à produção da prova testemunhal em audiência pública; (ii) a presenciar a produção da prova testemunhal; (iii) à produção da prova testemunhal na presença do julgador do mérito da causa; (iv) à imposição do compromisso de dizer a verdade às testemunhas; (v) a conhecer a verdadeira identidade das fontes de prova testemunhal; (vi) a inquirir as fontes de prova testemunhal desfavoráveis, de forma contemporânea à produção da prova testemunhal. A esse rol parece razoável acrescentar o direito do acusado a se comunicar de forma livre, reservada e ininterrupta com o seu defensor técnico, durante a inquirição das testemunhas. (MALAN, Diogo Rudje. Direito ao Confronto no Processo Penal. Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2009, p. 87.)

No caso concreto, a natureza e a quantidade da droga são perfeitamente compatíveis com a finalidade de consumo próprio. Por outro lado, não há prova de mercancia da droga, o que, apesar de não ser essencial ao tipo do tráfico, conferiria segurança para afastar a finalidade do exclusivo uso.

Com estas observações, é mesmo caso de desclassificar a imputação do art. 33 da Lei n. 11343/06 para o art. 28 da mesma lei.

Os dois acusados foram presos em flagrante e permaneceram custodiados por dois dias, entre 17 e 18 de abril de 2019, contando-se dos dias de prisão na forma recomendada pelo Código Penal. Ainda que sejam apenas dois dias, o tempo de prisão é mais severo e gravoso do qualquer reprimenda que poderia ser imposta em caso de condenação pelo delito do art. 28 da Lei n. 11343/06. Na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se, neste caso, o reconhecimento do exaurimento do direito de exercício da pretensão punitiva como forma de reconhecimento, pelo Estado, da prática de coerção cautelar desproporcional no curso do processo em desfavor do acusado (HC n. 390038/SP, rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, por unanimidade, j. 06.02.2018). Esta decisão também não configura reincidência, com fundamento no mesmo julgado daquela Corte Federal.

Ante o fundamentado e por tudo mais que dos autos consta, resolvo o mérito da ação penal e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para ABSOLVER, na forma do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, o acusado WALDEMIR ANTÔNIO MATRICARDI da imputação do cometimento de crime descrito na denúncia e JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE dos acusados MARCIANO PIRES SIMÕES e CARLOS ROCHA ARAÚJO por aplicação da detração penal analógica virtual, pois qualquer pena aplicável ao caso concreto estaria fatalmente cumprida, nem havendo justa causa ou interesse processual para o prosseguimento do feito.

Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários advocatícios do convênio firmado entre OAB/SP e DPESP. Oportunamente, elabore-se a competente certidão de honorários advocatícios.

Determino a destruição das drogas, inclusive amostras guardadas como contraprova, vinculada à prova destes autos, na forma do art. 72 da Lei n. 11343/06.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diligências necessárias. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa.

Viradouro, 18 de maio de 2022.

PEDRO HENRIQUE ANTUNES MOTTA GOMES

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA